

1500029-76.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2003816/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 3024215 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 452/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2003816 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500029-76.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500029-76.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2003816/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 3024215 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 452/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2003816 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 452/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHIRLEY VIRGINIO CAMARGO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

SHIRLEY VIRGINIO CAMARGO e LEANDRO HENRIQUE FRANCO LUIZ foram dados como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 11h20, no Centro de Detenção Provisória de Bauru, nesta comarca, traziam consigo, para fins de tráfico, 176,80 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificados (fls. 107 e 108), os réus apresentaram as defesas preliminares de fls. 100/101 e 121/122.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 13 de março de 2.019 (fls. 129/130). Em audiência, foram ouvidas testemunhas, o réu Luiz foi interrogado e foi decretada a revelia de Shirley (fls. 166 e 414 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 441/444).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 452/476, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- o réu Luiz afirmou que apenas aguardava a visita da acusada Shirley, nada sabendo sobre o fato de ela estar na posse de entorpecente; 3)- a ré não conseguiria entrar com a droga na unidade prisional, pois teria que passar pelo equipamento de scanner corporal; 4)- os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária não são suficientes para a condenação; 5)- a ré Shirley faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, com relação a Shirley, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 14 e pelo laudo pericial de fls. 434/437 (uma porção de maconha com peso de 176,80 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos à ré Shirley, mas não ao corréu Leandro.

Interrogada na polícia, a acusada Shirley declarou ter sido surpreendida durante a revista por meio do scanner corporal, na posse de drogas escondidas em seu órgão sexual. Praticou a conduta a pedido de seu companheiro Leandro, que está preso na unidade prisional em questão. O entorpecente lhe foi entregue por pessoa desconhecida, no centro da cidade, e seria destinada a Leandro. O desconhecido prometeu pagar certa quantia em dinheiro para seu marido, assim que ela adentrasse no estabelecimento prisional. Estava passando dificuldades e, por isso, concordou em levar a droga (fls. 41).

Ouvido na polícia, o réu Leandro afirmou não saber detalhes do ocorrido. Estava no pavilhão e ouviu dizer que sua visitante houvera sido flagrada na posse de maconha, no momento em que ela ingressava na unidade prisional. Nada teve a ver com a situação (fls. 44).

Em juízo, a testemunha Sheila Regina Neves Maitan, agente de segurança penitenciária, afirmou que a acusada entrou na fila e logo disse que precisava ser atendida de forma rápida pois estava menstruada e necessitava se limpar. Ela foi submetida ao scanner e constatou-se que havia um objeto introduzido na região vaginal. Ela sangrava muito e foi levada ao banheiro. Verificou-se que ela estava tendo uma hemorragia. Conversando com a ré, ela retirou um invólucro grande do corpo. Naquele momento, a hemorragia aumentou muito e o SAMU foi acionado. A ré foi conduzida até a maternidade e encaminhada ao centro cirúrgico. O médico falou que ocorreu uma laceração vaginal. O objeto expelido era um invólucro de maconha. A acusada confessou que levava entorpecente para a unidade, disse ser moradora e rua e que precisava ingressar com o material. Não se lembra se ela indicou o destinatário da droga. A acusada disse que receberia uma quantia como pagamento. Não se lembra do montante em questão, mas era quantia irrisória. Depois que ela entrou no centro cirúrgico, não teve mais contato com a mesma. A ré deu entrada na unidade prisional para visitar o corréu Leandro. Não o conhecia e não manteve contato com ele na ocasião. Ela o visitava praticamente toda semana.

A testemunha Abner Dutra, agente de segurança penitenciária, disse que sua colega Sheila revistou a acusada e encontrou drogas em poder dela. Acompanhou a ré até a delegacia para registro da ocorrência. Não presenciou a abordagem, pois são as agentes femininas que fazem a revista. Na época, já havia o body scanner na unidade prisional. Quando há suspeita de posse de objeto ilícito durante a revista pelo equipamento, o visitante é conduzido a uma sala reservada. Viu a ré na fila para entrar no estabelecimento prisional. Naquele primeiro momento, não havia notado nada de estranho com ela. Não a viu passar pelo scanner, pois é uma agente mulher que acompanha o procedimento. Quando Sheila indagou a acusada, ela confirmou que levava o entorpecente para seu companheiro. Presenciou a conversa de Sheila com a

ré. Não se lembra se teve contato com o réu Leandro, companheiro da acusada, na data em questão.

Interrogado em juízo, o réu Leandro negou a prática do delito. Na ocasião, aguardava a visita da ré. Não tinha ciência de que ela trazia drogas. Estava preso em outro "B O". Depois de ganhar a liberdade e sair para a rua, a ré lhe contou que, na porta da cadeia, ofereceram-lhe dinheiro para entrar com o entorpecente. Não sabe por que ela disse ao delegado e à agente que iria levar a droga para ele, réu. Shirley somente contou ter aceitado entrar com a droga porque precisava de dinheiro, que lhe houvera sido prometido por alguém na entrada da unidade prisional.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação da acusada Shirley nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

Em solo policial, ela confessou a prática do crime.

Lembre-se que a confissão extrajudicial é relevante elemento de convicção.

Nesse sentido:

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil." (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

No caso, a confissão extrajudicial restou corroborada sobretudo pelo depoimento da agente de segurança penitenciária Sheila, que identificou a presença de objeto estranho no corpo da acusada durante o procedimento de revista através do scanner corporal, bem como que verificou tratar-se de maconha.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Portanto, ao menos no tocante à Shirley, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria restaram bem evidenciados.

Por outro lado, não há dúvida de que a acusada estava praticando o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso em tela, a ré foi flagrada trazendo na cavidade vaginal nada menos do que

176,80 gramas de maconha, no momento em que tentava adentrar na unidade prisional, local onde a mercancia de entorpecentes ocorre com frequência. Ademais, em se tratando de visita de apenas um dia, não há como conceber que ela faria uso de todo material apreendido apenas naquela ocasião, no interior do estabelecimento prisional.

Sendo assim, não é possível que a ré tenha agido com finalidade outra que não a entrega da droga a terceiro.

Neste sentido:

"Portanto, para a correta tipificação da conduta, é fundamental que o Julgador verifique as particularidades do delito, atentando-se à natureza e quantidade da droga, bem como ao local em que se desenvolveu a ação delitiva, às circunstâncias nas quais estava o agente. In casu, foram arrecadadas 3,60g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack", sendo certo que a aludida droga estava separada em vinte e uma porções, propícias ao comércio." (TJ-MG, Apelação Criminal 10481100114174001, Des. Rubens Gabriel Soares - Relator).

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, deve a ré ser condenada pelo tráfico de drogas.

Solução diversa se impõe quanto ao acusado Leandro.

Em que pese a ré Shirley ser cadastrada como visitante do corréu e de ter dito aos agentes e ao delegado de polícia que iria lhe entregar a droga, não restou demonstrada a inequívoca ciência de Leandro quanto à conduta de sua esposa.

Primeiro, porque, tal qual ocorre com a confissão, a delação informal e mesmo aquela prestada formalmente em solo policial, quando isoladas, não se prestam à condenação.

Confira-se, à propósito, o seguinte julgado, que diz respeito à confissão extrajudicial e formal:

"Sentença absolutória. Apelo ministerial. Condenação por tráfico. Impossibilidade. Confissão em solo policial que restou isolada nos autos. Ausência de outros elementos a corroborar a confissão extrajudicial. Admissão apenas da posse para uso próprio. Condenação pelo art. 28. Possibilidade. Fixada a pena de advertência. Detração anômala. Ocorrência. Apelo ministerial parcialmente provido e julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento." (TJSP, Apelação n. 0001175-05.2010.8.26.0220, rel. Souza Nucci, j. 16/12/2013).

Socorre-se, uma vez mais, de precedente jurisprudencial, para afirmar a imprestabilidade da confissão informal enquanto elemento de convicção suficiente à condenação:

"Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Confissão informal de Adriana, mencionadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, que não foi confirmada pelas demais provas. Impossibilidade de condenação exclusivamente com base em elementos de provas colhidos na fase inquisitiva. Art. 155 do CPP.

Absolvição mantida." (TJSP, Apelação n. 0000500-40.2017.8.26.0594, rel. Reinaldo Cintra, j. 20 de junho de 2.018).

Do corpo do acórdão, destaca-se:

"Quanto a Adriana, em que pese os policiais responsáveis por seu flagrante tenham dito que ela assumiu a traficância informalmente, fato é que tanto na fase policial como em juízo Adriana negou envolvimento com o tráfico, e o corréu Maykon a isentou de responsabilidade, sendo certo que, conforme bem salientado na r. sentença, a confissão informal, sequer confirmada na delegacia, restou isolada nos autos."

Insista-se, pois, que, se a confissão formal e extrajudicial e a confissão informal, quando isoladas, não se prestam à condenação, com maior dose de razão não

é viável a procedência da ação penal com base em delação formal/extrajudicial e em delação informal, até porque, na delação, diferentemente da confissão, sequer há qualquer participação do acusado, sendo nítida a inobservância do contraditório. Não bastasse, deve-se ainda atentar para o exato teor do interrogatório da acusada na fase inquisitiva.

Ela disse que a droga lhe foi entregue por um desconhecido no centro da cidade, desconhecido esse que houvera prometido pagar ao seu marido certa quantia em dinheiro (fls. 41).

Embora a acusada também tenha afirmado que levava a droga "a pedido do meu companheiro Leandro", aquela outra afirmação deixou dúvida da participação do corréu, pois não se pode descartar que Shirley tivesse ouvido apenas do desconhecido que o entorpecente se destinava ao seu marido, sem de fato ter checado a informação com este último.

Note-se que tal probabilidade não resta excluída por nenhuma consideração lógica, haja vista ser possível que um terceiro criminoso qualquer, interessado na introdução de droga no interior de unidade prisional, para melhor persuadir uma visitante a ali ingressar com o material ilícito, diga-lhe que o entorpecente seja destinado ao marido dela, sem que de fato alguma combinação prévia com este tenha ocorrido.

E não se olvide ser igualmente possível que, assim que houvesse o ingresso da visitante no estabelecimento prisional, o verdadeiro destinatário da droga logo se apresentasse e a recebesse.

De resto, sabe-se ser comum o recrutamento de mulheres por pessoas de fora do mundo prisional, para que elas adentrem no presídio com entorpecentes.

Em razão da dúvida, deve o réu Leandro ser absolvido.

Passa-se à aplicação da pena.

A ré é primária e não registra antecedentes (fls. 68).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei 11.343/06.

Assim, eleva-se a pena na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável ao caso a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade e ausência de antecedentes, não se evidenciou ser a acusada pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

A quantidade de drogas apreendida, notadamente se se levar em conta tratar-se de maconha, não foi das mais elevadas, não sendo possível inferir, pois, a partir de tal dado, que se trata de agente dedicada a atividade criminosa.

Acrescente-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida. Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena.

Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado.

Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 – A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de

'atividade criminosa'. 2 – Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se

afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 – Recurso provido, para reduzir a pena

em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. '1.085.039/MG, rel. Min. Maria

Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-

62.2013.8.26.0071).

No mesmo sentido:

"Habeas corpus. Tráfico transnacional de drogas. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fundamentação inidônea. Inversão do ônus da prova. Inadmissibilidade. Precedentes. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio do 'in dubio pro reo'. Precedentes. Ordem parcialmente concedida apenas para afastar o óbice à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo a fixação do 'quantum' ser realizada pelo juízo do processo de origem, ou, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, pelo juízo da execução da pena."

(STF, 2ª Turma, HC n. 103225/RN, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 21/11/2011) (idem). Aliás, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reformou entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de restabelecer a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim decidiu o eminente Ministro:

"Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito, essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Da leitura da decisão transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. O Tribunal de origem destacou que a paciente 'se dedicava à atividade ilícita de modo habitual e reiterado, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e que das circunstâncias em que foi surpreendida pelos policiais militares, isto é, por volta de 1h25 (...) tudo a indicar que não era principiante e fazia do comércio ilícito seu meio de vida, emergindo inegável, portanto, o seu envolvimento com atividade criminosas, notadamente com traficantes de maior porte, seus fornecedores ou patrões." Contudo, não há nos autos nenhum elemento probatório apto a provar a afirmativa de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, especialmente quando se observa que o Parquet somente arrolou como testemunhas os policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ora, a configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos e não de meras ilações, sem correspondência fática. O envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, como apontou a decisão atacada, pressupõe que o agente, no mínimo, pratica ou praticou diversos atos ou, ao menos, está inserido em grupo/organização direcionada ao crime. Entretanto, o ônus de provar tais elementos que afastam a redutora é da acusação, não cabendo ao magistrado colher elementos extraprocessuais para imputar uma reprimenda mais severa, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, o caso trata de condenação pelo tráfico de 7,67 (sete gramas e sessenta e sete decigramas) de maconha, mais 4,5 (quatro gramas e cinquenta decigramas) de cocaína, ou seja, não se trata de quantia vultosa como afirmado no acórdão proferido pelo TJSP. Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tem o paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de traficante primária e não há nenhuma indicação de maior envolvimento em atividades ilícitas." (Habeas Corpus n. 137458/SP, j. 29/09/2016).

A pena, no entanto, não deve ser reduzida na proporção máxima de dois terços. Isto porque, se a quantidade de droga apreendida não era das maiores, era ao menos razoável (176,80 gramas de maconha).

Sendo assim, reduz-se a pena na proporção de um terço, resultando em três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, mais trezentos e oitenta e oito dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar

que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, quantidade não muito elevada de droga), fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para: 1)- condenar a acusada Shirley Virginio Camargo como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, a cumprir três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar trezentos e oitenta e oito dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução. e; 2)- absolver o acusado Leandro Henrique Franco Luiz da acusação do cometimento do

delito descrito no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA